

1519523-21.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Magistrado: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... anos, sendo certo que até mesmo para o tráfico de drogas, substâncias proibidas atestadas pela ANVISA, a pena mínima é consideravelmente menor (metade). Assim sendo, seguindo o já decidido pelo E. STF, no RE 979.962, em regime de repercussão geral, a pena aplicada será aquela originária para o delito do artigo 273 do CP, qual seja de 01 a 03 anos de reclusão:

"(...) A maioria do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1519523-21.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519523-21.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2230669/2020 - 36º D.P. VILA MARIANA, 13644735 - 36º D.P. VILA MARIANA, 1602/20/236 - 36º D.P. VILA MARIANA, 2230669 - 36º D.P. VILA MARIANA, 2230669 - DIISP - 02ª DEL.POL., 1602/20/236 - DIISP - 02ª DEL.POL.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAN PEREIRA NEVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JONATAN PEREIRA NEVES, narrando que no dia 17 de setembro de 2020, por volta das 15hs:00, na Rua Loefgreen, n. 1209, Saúde, nesta cidade e comarca da Capital, JONATAN PEREIRA NEVES, qualificado a fls. 10, durante o período de calamidade pública, tinha em depósito para a venda, ou, de qualquer forma, para a entrega a consumo de produto sem registro no órgão de vigilância sanitária

competente. Segundo o apurado, Policiais Civis receberam denúncia anônima de que um indivíduo vendia medicamento abortivo, conhecido como "Cytotec", nas imediações do Shopping Santa Cruz. Deslocaram-se para o local indicado e, após breve campanha, observaram a aproximação do veículo indicado, sendo que uma mulher, não identificada, aproximou-se da janela do carro. No momento da abordagem policial, aquela evadiu-se, sendo detido o denunciado. Requer, ao final, a condenação do Réu nas penas do crime do artigo 273, §1º - B, incisos I, V e VI, e artigo 61, inc. II, letra "j", ambos do Código Penal.

Decisão recebendo a denúncia no dia 10 de agosto de 2001, como se vê de fls. 155/156.

Devidamente citado, o Réu apresentou sua resposta à acusação às fls. 203/220, alegando a inconstitucionalidade da pena do artigo 273 do CP, pela violação da proporcionalidade, bem como o erro de proibição, pois não sabia que a venda de tais comprimidos era tipificado como crime, além da desclassificação para a modalidade culposa.

Folha de antecedentes criminais do acusado às fls. 172.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 30/05/2022, em que foram ouvidas as testemunhas e ao final colhido o interrogatório do Réu.

Alegações finais do MP apresentadas em audiência e em seguida da defesa apresentadas via memoriais

É o relatório. Passo a decidir.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição/apreensão de fls. 11/12, laudos periciais de fls. 176/179, fls. 180/183 e fls. 184/187, bem como depoimentos orais prestados não apenas em sede policial, mas corroborados em contraditório judicial, como quer o artigo 155 do CPP.

A testemunha policial BRUNO afirmou em juízo que: "recebeu uma denúncia anônima informando que o Réu comercializava clandestinamente um remédio abortivo. De posse de tais informações, fizeram campanha no local, e viram um carro estacionar ao seu lado (um Celta) e entregar uma cartela com quatro comprimidos do remédio "Cytotec". Afirma que a moça que saiu do carro para contatar o acusado conseguiu fugir, e que o Réu afirmou no local que estava apenas entregando o remédio. Afirma que a cartela estava cortada, mas dava para ler o nome Cytotec". O depoimento supra foi corroborado de forma firme e coerente pelo seu colega de fardas, o também policial e testemunha YURI.

O depoimento policial/GCM prestado corrobora os fatos descritos na denúncia, merecendo, portanto, credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos. Como se sabe, é através do trabalho da polícia/GCM que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los. Assim, ressalvada hipótese de restar comprovada animosidade contra o réu, ou verdadeiro interesse na prolação do desate condenatório, seus depoimentos não podem ser desconsiderados, ainda mais porque milita em favor deles a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade.

Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 74.608-0 - Rel. Min. Celso de Mello - j. 18/02/97).

Como deve ser em todos os ritos, o último ato da instrução foi o interrogatório do Réu JONATAN, que em sua autodefesa afirmou que: "sua namorada comprou o remédio

Cytotec e pediu para ele ir até o Shopping Santa Cruz pegar o remédio para ela. Afirmar que foi até o Shopping Santa Cruz, em seu Celta preto, e a mulher vendedora entregou o produto para ele, e saiu correndo. Afirmar que foi preso naquele momento. Afirmar que sabia que o remédio era para evitar a gravidez, mas não sabia que era ilícito". Negou, portanto, o cometimento do delito.

Trata-se, pois, do delito do artigo 273, §1º - B, incisos I, V e VI, do CP.

O presente crime é norma penal em branco heterogênea. Isso porque, precisa de complemento de outra fonte normativa para tornar sua subsunção perfeita. No caso em tela, o complemento é fornecido pela Portaria SVS/MS n/344/98 expedida pela ANVISA. Assim sendo, o produto apreendido com o Réu deve estar nesta lista, para que sua conduta seja típica.

Cinge-se o caso em tela de delito que deixa vestígio, e com base no artigo 158 do CPP, é preciso ser comprovado mediante prova pericial. Ademais, necessária a análise de um especialista imparcial para informar a este Juízo se o fármaco apreendido se encontra inscrito no ato administrativo supramencionado.

Nessa toada, o laudo pericial de fls. 186 concluiu que: "O material submetido a exame é produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais? Qual sua especificação? Possui registro no órgão de saúde pública e/ou vigilância sanitária?

RESPOSTA: Misoprostol é um fármaco indicado no tratamento e prevenção de úlcera gástrica, tendo também utilidade em obstetrícia por causar contração uterina e amolecimento do colo uterino, levando à indução de trabalho de parto ou aborto. Dessa forma, apresenta potencial abortivo e se encontra incluído na lista C1 de substâncias sujeitas à receita de controle especial em duas vias da Portaria SVS/MS n/344/98. O produto comercial "Cytotec" não possui registro na Agência Nacional da Vigilância Sanitária (ANVISA)".

A tese de erro de proibição é absolutamente infundada. A uma por questões fáticas: ora, remédio se compra na farmácia. O Réu foi se encontrar clandestinamente nas proximidades de um Shopping para receber uma cartela de remédios de uma pessoa que nunca viu na vida. A duas por questões jurídicas, já que o desconhecimento da lei é inescusável (art. 21, 1ª parte do CP). O Réu se demonstrou esclarecido o suficiente para saber (ou dever saber) que o ato abortivo é criminoso, além de ter corroborado a assunção da possibilidade de sua namorada estar grávida, eis que afirmou ter tido relações sexuais sem preservativo, bem como ter procurado pílula do dia seguinte na drogaria, quando foi informado que àquela altura já não adiantaria.

Passo à dosimetria da pena.

Primeiramente, há de se constar a razão defensiva quando alega a desproporcionalidade da pena do delito em tela. Isso porque, o preceito secundário previsto em lei é de reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, sendo certo que até mesmo para o tráfico de drogas, substâncias proibidas atestadas pela ANVISA, a pena mínima é consideravelmente menor (metade). Assim sendo, seguindo o já decidido pelo E. STF, no RE 979.962, em regime de repercussão geral, a pena aplicada será aquela originária para o delito do artigo 273 do CP, qual seja de 01 a 03 anos de reclusão:

"(...) A maioria do Plenário, contudo, entendeu que, como decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, deve incidir o efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão. 8. Recurso do Ministério Público Federal desprovido. Recurso de Paulo Roberto Pereira parcialmente provido. Tese de julgamento: É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária". (RE 979962, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/2021).

O caso em tela não foge à normalidade das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, que devem se manter neutras, além de não ter qualquer circunstância atenuante ou agravante, face à primariedade do acusado, bem como sua confissão parcial, o que, todavia, não pode diminuir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ), e ainda a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena. Por isso, a pena

deve ficar no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o ABERTO, tendo em vista o quantum de pena aplicado, bem como a primariedade do acusado, nos termos do artigo 33 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia ministerial para fins de CONDENAR o Réu JONATAN PEREIRA NEVES, como incurso no delito do artigo 273, §1º - B, incisos I, V e VI, do CP, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão no regime inicial aberto, bem como 10 (dez) dias-multa, cujo valor é fixado no mínimo legal, ante à ausência de informações quanto à situação econômica do acusado.

Não havendo pedido expresso na inicial, deixo de fixar a indenização do artigo 387, IV do CPP, sob pena de violação do princípio da congruência (STJ - AgRg no AREsp 1309078 /PI).

Ante a primariedade técnica do acusado, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, pelo mesmo período da pena corporal, à entidade a ser definida em sede de execução, nos termos do art. 44 e seguintes do Código Penal.

Considerando que o Réu respondeu ao processo em liberdade, e não estando presentes os requisitos da segregação cautelar máxima do artigo 312 do CPP, concedo ao Réu o direito de apelar em liberdade.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe, mormente o TRE (art. 15, III da CRFB/88) e o IIRGD e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Decreto, em favor da União, a perda dos instrumentos, produtos e proveitos do crime em análise (art. 91, II do CP), ou seu valor equivalente, caso estes não sejam encontrados ou estejam no exterior (§1º).

Custas pelo réu, nos termos do artigo 804 do CPP, ficando-lhe concedidos, porém, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.

São Paulo, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA